

1501911-97.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL RAUCH

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... em atitude suspeita e típica de tráfico de entorpecentes, antes de realizarem a abordagem. O local, aliás, é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes.

Nesses termos, havendo justa causa para o ingresso dos policiais no barraco onde entrou um dos acusados, nada há que se falar em ilicitude probatória.

As provas, portanto, são bastantes para a condenação.

No que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi-SP - cep 06660-280

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501911-97.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501911-97.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2268309/2021 - DEL.POL.ITAPEVI, 20594920 - DEL.POL.ITAPEVI, 2796/21/407 - DEL.POL.ITAPEVI, 2268309 -

DEL.POL.ITAPEVI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIANS VINICIUS JALES DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL RAUCH

Vistos.

WILLIANS VINICIUS JALES DE OLIVEIRA e GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificados nos autos da Ação Penal em epígrafe que lhes move a Justiça Pública, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Isso porque, no dia 1.º de outubro de 2021, por volta das 2h40min, na Rua Santo Antônio, altura do n.º 10, Jardim Itapevi, nesta cidade e Comarca de Itapevi, os réus, previamente ajustados e com unidade de desígnios, guardavam, tinham em depósito e traziam consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os réus foram notificados (f. 112 e 119) e apresentaram defesa prévia (f. 132 e 133).

Não sendo caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária, a exordial acusatória foi recebida por decisão datada de 25 de abril de 2022 (f. 135-136). Os réus foram citados, dando-se seguimento à persecução penal em Juízo. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, tendo-se interrogado os réus ao final (f. 197). Na sequência, encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais (f. 201-207 e 224-227).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa aos acusados a prática da infração penal prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Não havendo questões de admissibilidade a serem analisadas e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de f. 15-16, que atesta terem sido apreendidos os entorpecentes em posse dos acusados, bem como a quantia de R\$ 2.265,00 em dinheiro.

As substâncias entorpecentes foram submetidas a exame pericial (f. 164-169), sendo que o resultado foi positivo para "crack", "cocaína" e "maconha", drogas de uso proscrito no Brasil.

Os réus, em seus interrogatórios, confessaram a prática dos fatos narrados na exordial acusatória.

As confissões, aliás, restaram corroboradas pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Deveras, os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram contestes nos pontos essenciais e confirmaram a ocorrência dos fatos descritos na denúncia. Relatam que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando viram os réus com atitude suspeita. Informam que outras pessoas chegavam até eles e falavam algo, havendo uma troca entre eles; após um tempo, o réu Willians Vinicius Jales de Oliveira foi até o fundo da comunidade e entrou num barraco. Acompanharam-no até esse barraco e o abordaram, momento em que ele mostrou as drogas e confessou que estava traficando. Dirigiram-se, então, até o acusado Gabriel Rodrigues de Oliveira e o abordaram também; ele tinha uma sacola em mãos, que continha drogas em seu interior.

E nada há nos autos que indique eventual intenção espúria dos policiais militares de incriminar injustamente os acusados. Assim, seus depoimentos merecem credibilidade e são valiosos para a condenação. Entendimento contrário acarretaria a ruína do sistema de segurança pública do Estado.

Frise-se, nesse passo, que as circunstâncias da abordagem, noticiadas nos depoimentos dos policiais, permitem presumir que as drogas apreendidas com os acusados se destinavam ao tráfico, não havendo espaço para eventual desclassificação da conduta praticada.

Importante ressaltar que o flagrante está de acordo com a tese do Tema n.º 280 de Repercussão Geral do STF, que assim aduz: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

Isso porque há nos autos elementos anteriores à apreensão das drogas dentro do barraco que caracteriza a hipótese permissiva constitucional de flagrante delito. Veja-se, a entrada no domicílio, para configurar a exceção de hipótese de flagrante delito constitucionalmente prevista (art. 5.º, XI, da CF), deve ser precedida de justa causa, isto é, exigem-se provas anteriores que gerem fundada suspeita de que o sujeito está praticando algum delito.

No caso concreto, os policiais narram que observaram de longe algumas pessoas chegando até os réus e dizendo algo, havendo a troca de alguma coisa entre eles.

Após um tempo de observação, um dos réus se dirigiu até o barraco - e foi nesse momento que ocorreu a abordagem.

Tem-se, portanto, que os policiais observaram os acusados em atitude suspeita e

típica de tráfico de entorpecentes, antes de realizarem a abordagem. O local, aliás, é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. Nesses termos, havendo justa causa para o ingresso dos policiais no barraco onde entrou um dos acusados, nada há que se falar em ilicitude probatória.

As provas, portanto, são bastantes para a condenação.

No que tange à aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, atento aos recentes julgados dos tribunais superiores sobre o assunto, revejo posicionamento anterior e passo a não vislumbrar inconstitucionalidade na incidência deste privilégio.

Explica-se.

A Terceira Seção do C. STJ, embora não tenha se pronunciado diretamente sobre a inconstitucionalidade ou não da causa especial de diminuição de pena em tela, ao revisar o REsp n.º 1.329.088/RS, afetado para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (arts. 1.036 e seguintes do CPC), no Tema n.º 600, firmou a seguinte tese: "O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo".

Com a revisão da tese anterior, o tribunal superior cancelou seu enunciado de súmula n.º 512, que assim dispunha: "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas".

Foram, outrossim, compiladas as seguintes teses sobre o tema, na edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ:

21) O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600)

22) A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes.

23) É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.

25) Diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito.

45) A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar bis in idem.

46) A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF.

48) A utilização da reincidência como agravante genérica é circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico, e não caracteriza bis in idem.

Em todos esses enunciados, bem como no Tema Repetitivo n.º 600, o C. STJ admitiu indiretamente a viabilidade de incidência da circunstância privilegiadora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, desde que observados cumulativamente os requisitos do dispositivo.

Também o STF firmou tese admitindo a aplicação do privilégio ao delito de tráfico, no julgamento do Tema n.º 712 de Repercussão Geral, no qual se firmou a seguinte tese: "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena".

Desse modo, nada há que se falar sobre eventual inconstitucionalidade da norma disposta no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

No caso concreto, é incabível a aplicação da forma privilegiada do tráfico, eis que não observados cumulativamente todos os requisitos para sua aplicação.

Com efeito, o réu Gabriel Rodrigues de Oliveira afirmou em seu interrogatório que

estava traficando naquele local há cinco meses. O acusado Willians Vinicius Jales de Oliveira, por sua vez, em seu interrogatório prestado em solo policial, forneceu versão semelhante, de que traficava há oito meses (f. 06).

Nenhum dos réus trabalha ou terminou os estudos, e eles traficavam em tempo integral, de modo que o tráfico não era praticado por eles de forma eventual e esporádica, mas rotineiramente – o que caracteriza a dedicação deles ao crime. Inviável, nesses termos, a incidência da circunstância privilegiadora.

Nessa conjuntura, verifica-se que há subsunção das condutas dos acusados ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que, previamente ajustados e com unidade de desígnios, com vontade e consciência, guardavam, tinham em depósito e traziam consigo as porções de drogas indicadas na denúncia, sem autorização legal ou regulamentar.

O fato é ilícito, pois reprovado pela lei penal, sendo que não foram alegadas ou comprovadas quaisquer causas justificantes.

Os denunciados eram maiores de 18 anos de idade (imputáveis), tinham potencial consciência da ilicitude e, nas circunstâncias, era-lhes exigida conduta diversa. Presente, portanto, a culpabilidade.

Assim, passo a aplicar a pena, seguindo o método trifásico previsto no art. 68 do CP.

Inicialmente destaco que este Juízo, para a estipulação da pena base e o cálculo do aumento decorrente de eventual circunstância judicial – inclusive para a aferição de pena de multa cominada isolada ou cumulativamente –, leva em consideração o resultado do intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt: “O critério que vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores repousa numa situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo da pena prevista em abstrato ao tipo (máximo – mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir o resultado obtido por 8 (oito), em vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Com esse raciocínio, chegamos ao patamar exato de valoração de cada uma das circunstâncias judiciais (com absoluta proporcionalidade), o qual servirá de parâmetro para o julgador promover suas análises individuais” (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Podivm. 6ª edição. Salvador/Bahia. 2011. p. 115/116).

A par disso, para a hipótese específica destes autos, incide o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que assim dispõe, in verbis: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Neste cenário normativo, verifica-se que dois vetores do art. 42 da Lei de Drogas já estão inseridos expressamente nos parâmetros do art. 59 do CP – “personalidade e conduta social do agente”. Outrossim, tem-se que “a natureza e a quantidade da substância ou produto” podem ser analisadas no contexto das “circunstâncias” do delito, outro vetor do art. 59 do CP.

Assim, e pela necessidade da “preponderância” prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, alvitra-se valorar a personalidade e a conduta social do agente, assim como as circunstâncias do delito, com um peso mais significativo.

Como ressaltado anteriormente, costuma-se considerar o intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito. Todavia, para preponderância aqui perseguida, prudente que a divisão seja feita por 11, uma vez que as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas podem ser enquadradas em três vetores, tal como delineado acima – personalidade, conduta social e circunstâncias.

Fazendo isso, porém, deve-se dar aos vetores preponderantes o peso de 2/11, e aos demais, o de 1/11.

Assim, nos termos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/06, à culpabilidade, aos antecedentes, aos motivos e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima (irrelevante em se tratando de crime vago como o tráfico de drogas), deve-se atribuir o peso de 1/11, constituindo 5/11 da pena-base; à conduta

social e à personalidade do agente, assim como às circunstâncias, deve-se aplicar o peso de 2/11, configurando 6/11 da pena-base.

Desse modo, estará garantida a aplicação preponderante do art. 42 da Lei de Drogas, bem como assegurada, de forma mais escorreita e técnica, a individualização da pena.

Todavia, é necessário ressaltar que a fração indicada não deve ser aplicada de forma precisa, matematicamente. Trata-se, na verdade, de mero parâmetro para a fixação da reprimenda penal, de modo que as circunstâncias do caso concreto podem ensejar a exasperação maior ou menor da pena – ou maior ou menor compensação em caso de vetores favoráveis.

Feitas essas observações, à dosimetria da pena.

Pois bem, o acusado Willians Vinicius Jales de Oliveira é primário e não ostenta maus antecedentes (f. 159).

O réu Gabriel Rodrigues de Oliveira possui uma condenação com trânsito em julgado, a qual, contudo, será sopesada na segunda fase da dosimetria da pena (f. 156-158).

Por outro lado, importante ressaltar que, em seus interrogatórios (o réu Willians Vinicius Jales de Oliveira, em juízo, e o acusado Gabriel Rodrigues de Oliveira, em solo policial – f. 08), afirmaram ser usuários de drogas. Tal circunstância é desfavorável à conduta social dos denunciados, já que, além de traficarem drogas, financiam indiretamente esse delito equiparado a hediondo, crime esse que vem, cada vez mais, corroendo famílias e a própria sociedade.

Além disso, as circunstâncias do delito também são desfavoráveis. Com efeito, os denunciados estavam na posse de entorpecentes de naturezas diversas, maconha, cocaína e crack, essa última de altíssimo poder destrutivo. Outrossim, a quantidade dos entorpecentes apreendidos foi significativa (f. 164-169).

As demais circunstâncias do art. 59 do CP não são desfavoráveis aos réus, ou são normais aos tipos penais.

Nesse contexto, havendo duas circunstâncias judiciais preponderantes negativas, fixo a pena base desse delito, para ambos os réus, em 08 anos e 04 meses de reclusão – e 833 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea para os dois acusados, na forma do art. 65, III, “d” do CP, tendo em vista que ambos confessaram em juízo a prática do delito.

Reconheço, também, a agravante da reincidência em relação ao acusado Gabriel Rodrigues de Oliveira, tendo em vista que, conforme certidão de f. 156-158, ele cometeu o crime em tela depois de ter sido condenado definitivamente por outro delito, tal como dispõem os arts. 63 e 64, inciso I, ambos do CP.

Assim, em consonância com o C. Superior Tribunal de Justiça, que pacificou, no julgamento do EREsp n.º 1.154.752/RS (DJe 4.9.2012), o entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do CP, deixo de exasperar ou diminuir a reprimenda do réu Gabriel Rodrigues de Oliveira, mantendo-a no mesmo patamar da pena-base fixada, provisoriamente.

Noutro prisma, ante a atenuante da confissão espontânea, reduzo a reprimenda do réu Willians Vinicius Jales de Oliveira em 1/6, fixando-a, provisoriamente, em 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão – e 694 dias-multa.

Por fim, na última fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, fixo as reprimendas, agora definitivamente, em: (a) 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão – e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa para o réu Willians Vinicius Jales de Oliveira; e (b) 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão – e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa para o acusado Gabriel Rodrigues de Oliveira.

O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país na data dos fatos, considerada a presumida precariedade da situação financeira dos denunciados, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

De acordo com o art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 8.072/90, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade para ambos os réus.

Ressalte-se, nesse passo, que é inconstitucional a Lei n.º 12.736/2012, que

determina a consideração da detração penal para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Isso porque viola o princípio constitucional da isonomia, já que, aplicando-se a referida lei, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais. Assim, o sentenciado condenado à pena privativa de liberdade, e que tenha sido preso provisoriamente, terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovido de regime sem a observância do seu comportamento carcerário (requisito subjetivo). Por outro lado, o condenado que não tenha cumprido prisão provisória deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais, a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5.º, caput).

Dessa forma, deixo de aplicar a Lei n.º 12.736/2012.

A detração deverá ser observada pelo juízo da execução, não havendo qualquer prejuízo aos acusados.

Mantenho a custódia cautelar do denunciado Gabriel Rodrigues de Oliveira, pois não modificadas as situações que determinaram a sua necessidade. Recomendo o réu na prisão onde se encontra.

Não há razões cautelares para a prisão preventiva do acusado Willians Vinicius Jales de Oliveira. Além disso, o Ministério Público, em seus memoriais, não requereu a decretação da custódia cautelar. Assim, tendo em vista o disposto no art. 311 do CPP (com redação dada pela Lei n.º 13.964/2019), deixo de decretar a prisão preventiva do acusado, que poderá recorrer em liberdade, se por outro motivo não estiver preso (CPP, art. 387, § 1.º).

Incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (CP, arts. 44, inciso I, e 77, caput).

Em razão do exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para os seguintes efeitos:

(a) condenar o réu WILLIANS VINICIUS JALES DE OLIVEIRA, já qualificado, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão - e ao pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, pela infração ao art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial fechado; e

(b) condenar o réu GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, já qualificado, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão - e ao pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, pela infração ao art. 33, caput e § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O valor do dia-multa fica estabelecido, para ambos os réus, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo federal vigente no país na data dos fatos, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

Expeça-se a guia de execução provisória em relação ao acusado Gabriel Rodrigues de Oliveira.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do art. 387, IV, do CPP, pois se trata de crime vago.

Determino a perda dos bens apreendidos a favor da União, nos termos dos arts. 91, II, do CP e 63, I, da Lei n.º 11.343/2006.

Custas pelos réus (CPP, art. 804), no valor de 100 UFESPs (Lei n.º 11.608/2003, art. 4.º, § 9.º, "a"), cuja exigibilidade fica suspensa em razão de estarem litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, que agora lhes fica deferida, anotando-se.

Após o trânsito em julgado:

(a) lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados ou instituto equivalente;

(b) expeçam-se as guias de execução definitivas;

(c) oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação dos réus, com suas devidas identificações, acompanhadas do inteiro teor da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelo art. 71, § 2º,

do Código Eleitoral combinado com o art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
(d) oficie-se ao Senad, nos termos do art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006; e
(e) arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias.

P.I.C.

Itapevi, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA